

1501619-05.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... e R\$ 85,00, provenientes do tráfico. O réu, admitindo o tráfico, indicou aos servidores públicos onde ocultava as restantes 65 porções da mesma droga. O guarda Felipe acrescentou que o local em que o réu se encontrava é conhecido como ponto de tráfico. Falou, ainda, que, sem a colaboração do denunciado, dificilmente a patrulha teria encontrado as últimas porções, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501619-05.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2288462/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 20967923 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2939/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2288462 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2288462 - 02º D.P. PIRACICABA, 2939/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA, 2288462/2021 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN HENRIQUE MONTEIRO MACHADO

Réu Preso

Contr. nº 2021/001135

Aos 12 de janeiro de 2022, às 14:30 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr. José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu LUAN HENRIQUE MONTEIRO MACHADO (preso CDP local). Presente o defensor Dr. Wesley Cesar Sabino Braga. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: GC FELIPE VIEIRA ALVES e GC Francisco Dernival Miranda Junior

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que, diante da restrição de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala,

inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa. Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (GC Felipe e GC Francisco) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).1. O(s) réu(s) LUAN HENRIQUE MONTEIRO MACHADO foi(ram) denunciado(s) e está(ão) sendo processado(s) como incurso(s) no art. 33 da LD. De acordo com a denúncia, no dia 21 de outubro de 2021, por volta de 15 horas, no cruzamento das ruas Querubim Sampaio e Alfredo Moreira Pinto, nesta cidade e comarca, LUAN trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 164 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 184,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 2. O processo teve trâmite regular. 3. A materialidade delitativa foi comprovada pelas peças seguintes: auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; auto de apreensão; laudo de constatação e laudo definitivo (fls. 1/5; 9; 12; 13/15; e 79/81). 4. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. O(s) depoimento(s) colhido(s) sob contraditório foi(ram) apto(s) a esclarecer que guardas civis se depararam com LUAN em conhecido ponto de tráfico. Notando a presença da patrulha, o acusado esboçou deixar o local e dispensou a sacola que trazia consigo e continha 89 porções de cocaína, posteriormente recolhida. LUAN foi abordado e submetido à busca pessoal. Resultou dessa providência a apreensão em seu poder de outras 10 porções de cocaína, idênticas às existentes na sacola já mencionada, e R\$ 85,00, provenientes do tráfico. O réu, admitindo o tráfico, indicou aos servidores públicos onde ocultava as restantes 65 porções da mesma droga. O guarda Felipe acrescentou que o local em que o réu se encontrava é conhecido como ponto de tráfico. Falou, ainda, que, sem a colaboração do denunciado, dificilmente a patrulha teria encontrado as últimas porções, pois estavam enterradas. O guarda Miranda informou que já conhecia o acusado e que já o prendeu em flagrante pelo mesmo motivo. Possui em seu poder uma filmagem, na qual o denunciado aparece indicando as últimas porções de droga. Interrogado, o réu negou os fatos. Disse que estava sentado no local com um amigo. Tinha em seu poder 85 reais. O amigo foi liberado pelos guardas. Não confessou o crime na Delegacia. Os depoimentos dos guardas não deixam dúvidas de que o réu foi surpreendido nas circunstâncias descritas na inicial. No cotejo entre as versões, prevalece a dos servidores públicos, cujos depoimentos são revestidos de credibilidade. 5. No tocante à aplicação da pena, observa-se que o réu não possui antecedentes desabonadores. A quantidade de drogas autoriza aumento na primeira fase da dosimetria e a opção pelo regime fechado. Sabendo-se que o réu responde a outro processo por outro crime de tráfico, já tendo sofrido condenação em 1º Grau (fls. 77), não faz jus ao privilégio. 6. Continuam presentes os requisitos da custódia cautelar. 7. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS, GRAVADAS EM ÁUDIO E VÍDEO.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

LUAN HENRIQUE MONTEIRO MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de outubro de 2021, por volta de 15 horas, no cruzamento das ruas Querubim Sampaio e Alfredo Moreira Pinto, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico e

consumo de terceiros, 164 "ependorfs" contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 184,4g (cf. laudo de constatação de fls. 13), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o acusado se dedica ao tráfico de drogas. Na data indicada, guardas civis se depararam com Luan em conhecido ponto de tráfico. Notando a presença da patrulha, o réu esboçou deixar o local e dispensou a sacola que trazia consigo e continha 89 porções de cocaína, posteriormente recolhida. O réu foi abordado e submetido à busca pessoal. Dessa providência resultou a apreensão em seu poder de outras 10 porções de cocaína, idênticas às existentes na sacola já mencionada, e R\$ 85,00, provenientes do tráfico.

Entrevistado, o acusado admitiu que se postou no local para traficar e mostrou aos servidores públicos onde escondia o restante da droga. No local indicado pelo réu foram encontradas mais 65 porções de cocaína, idênticas às porções anteriormente apreendidas. Na delegacia, Luan confessou o fato.

Conclui a denúncia que as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga evidenciaram a destinação ao tráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 86). Defesa preliminar apresentada às fls. 90/96. Após, a denúncia foi recebida (fls. 102) e o réu foi citado (fls. 130).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade. Pleiteou o afastamento do redutor do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, argumentando que o réu já respondia outro processo por tráfico de drogas e estava em gozo da liberdade provisória quando foi preso em flagrante nestes autos, demonstrando, assim, dedicação a tal atividade criminosa. Por fim, pediu a fixação de regime fechado para início do cumprimento de pena em razão da quantidade de drogas com ele apreendidas.

A Defesa pleiteou a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio, com a redução da pena em seu patamar máximo, a fixação de regime aberto para início do cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 06/08;
- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 09 e fotografia de fls. 12 e
- 4) laudo de constatação de fls. 13/15 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 79/81, ambos com resultados positivos para cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 04), o réu confessou o crime, admitindo que os entorpecentes e o dinheiro apreendido lhe pertenciam e que aqueles eram destinados ao tráfico, atividade que exercia em razão de estar desempregado e sua esposa grávida. Explicou que, no data dos fatos, quando os guardas municipais se aproximaram, jogou uma embalagem contendo 86 porções de cocaína ao solo, mantendo apenas 10 porções em sua posse e R\$ 85,00. Ao ser abordado, indicou aos agentes onde havia escondido mais 65 porções da mesma droga que iria vender. Por fim, disse que estava arrependido e informou que os guardas que o abordaram eram os mesmo que o prenderam anteriormente.

Interrogado em juízo (gravação), o réu se retratou e negou o crime, dizendo que estava sentado com um amigo no local dos fatos quando os guardas chegaram e os revistaram, encontrando R\$ 85,00 em seu poder, fruto do auxílio que recebia do governo. Disse que eles não encontraram drogas em seu poder, mas, mesmo assim, prenderam-no em flagrante dispensando seu amigo. Afirmou que nada tem contra os guardas que o detiveram, mas eles já o haviam abordado anteriormente e sempre

ameaçavam prendê-lo. Negou ter confessado o crime na delegacia e afirmou que nada tinha contra a Autoridade Policial que o interrogou. A negativa foi afastada pelas provas dos autos, as quais confirmaram a confissão extrajudicial.

Com efeito, ouvido na fase extrajudicial (fl. 02) e em juízo (gravação), o guarda civil Francisco Dernival Miranda Junior declarou que estavam em patrulhamento pela rua Querubim Sampaio quando, a uns 40 metros de distância, visualizaram o réu em pé, parado na esquina com a rua Alfredo Moreira Pinto, e viram que, ao perceber a aproximação da viatura, ele dispensou uma sacola ao chão. Diante disso e considerando que o local é conhecido como ponto de tráfico, abordaram-no e, em sua posse, no bolso de sua bermuda, encontraram 10 porções de cocaína e R\$ 85,00. Na sacola dispensada, encontraram mais 89 porções de cocaína, embaladas em microtubos idênticos aos que estavam com ele. O réu confessou o tráfico e, espontaneamente, disse que iria colaborar com os guardas, levando-os, assim, até um terreno baldio, ao lado de onde foi abordado, onde havia enterrado mais uma embalagem contendo 65 microtubos de cocaína, idênticos aos demais. Explicou que se o réu não tivesse indicado o local onde havia enterrado essas últimas drogas, dificilmente conseguiriam localizá-las. Afirmou que o réu assumiu a propriedade dos entorpecentes e disse que os estava vendendo porque estava desempregado e sua esposa estava grávida. Por fim, disse que atuaram em 3 guardas e um de seus parceiros já havia participado de outra ocorrência por tráfico envolvendo o réu. Explicou que havia outras pessoas na rua, mas não mantinham relação com ele. O réu recebeu voz de prisão quando encontraram as drogas em seu poder e ele admitiu que estava traficando.

No mesmo sentido as declarações prestadas pelo guarda civil Felipe Vieira Alves na fase extrajudicial (fls. 03) e em juízo (gravação), o qual acrescentou que, anteriormente, em local próximo, ele e o guarda William, motorista da viatura no dia dos fatos, já haviam prendido em flagrante o réu também por tráfico de drogas. Esclareceu que se lembrou dele somente quando o qualificaram.

Anoto que os relatos dos guardas civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando

for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos guardas civis: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registre-se que o fato de, em data anterior, um dos guardas que atuou na ocorrência em questão ter efetuado uma prisão em flagrante do réu também por tráfico em local próximo, não significa, por si só, que o perseguia ou o acusava injustamente com o mero intuito de prejudicá-lo. É comum os agentes realizarem patrulhamento na mesma região e não é difícil que prendam uma pessoa que insiste em desrespeitar as leis do Estado em flagrante delito no mesmo local por mais uma vez, em situações diversas.

Destarte, não há elementos que infirmem a palavra dos guardas.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que, no dia e local dos fatos, o réu trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 164 "eppendorfs" contendo cocaína, substância que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De fato, restou comprovado que os guardas municipais avistaram o réu parado no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, e perceberam que ele, ao visualizar a viatura, dispensou uma sacola ao solo. Tal atitude suspeita de tráfico de drogas motivou a abordagem e, em revista pessoal, os agentes encontraram com ele 10 porções de cocaína e dinheiro em notas diversas. Na sacola dispensada, localizaram mais 89 porções da mesma droga e, em local próximo indicado pelo próprio acusado, encontraram escondidos mais 65 porções de cocaína, todas embaladas de forma idêntica, o que não deixa dúvidas de que todos os entorpecentes lhe pertenciam.

Registre-se que o réu confessou tal fato perante a Autoridade Policial e, embora tenha se retratado em juízo, nada há nos autos que infirme os atos praticados por ela.

Ademais, nesta audiência, o réu alegou que no momento dos fatos estava acompanhado de um amigo que a tudo presenciou. Entretanto, sintomaticamente, a defesa não trouxe essa testemunha para ser ouvida no processo.

Inconteste, dessa forma, que as drogas apreendidas eram todas do réu e destinadas ao comércio, destino este que se reforça com a expressiva quantidade de entorpecentes, incompatível com a situação de mero usuário.

Some-se a tudo isso o fato de as drogas estarem embaladas na forma como comumente são comercializadas (fotografia de fls. 12) e de o réu portar dinheiro em notas trocadas, obviamente provenientes do comércio ilícito, eis que não comprovada a origem lícita.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-

11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

Não obstante responda a outro processo por tráfico de drogas pelo qual foi condenado em primeira instância, em razão do princípio da presunção de inocência, o réu deve ser considerado primário e de bons antecedentes, pois ainda não sofreu condenação definitiva (cf. F.A. de fls. 71/73 e certidão de fls. 77/78).

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis. A fim de se impedir o "bis in idem", a quantidade mais expressiva de drogas não será considerada nesta fase, mas na terceira para balizar a diminuição pelo privilégio.

Assim, aplico-lhe as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Inexistem agravantes.

Ainda que reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial, não seria caso de diminuir as penas, pois, circunstâncias atenuantes não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal.

Não há causas de aumento de pena.

Inexistindo comprovação da ocorrência de algum dos impeditivos do privilégio, elencados no parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06 (em razão do princípio da presunção de inocência, a existência de processo em andamento não permite a afirmação de que ele tem feito do crime seu meio de vida), possível a aplicação do redutor de que trata essa norma, mas não no percentual máximo permitido, eis que o tipo de droga apreendida e sua maior quantidade revelam maior gravidade da conduta, demonstrando que grande número de pessoas seriam prejudicadas pela conduta do acusado.

Nesse contexto, possível a redução das penas em 1/2, perfazendo dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa.

Quanto ao regime de pena, embora tecnicamente primário e tenha em seu favor o princípio constitucional da presunção de inocência, não se pode ignorar que, na época dos fatos, o acusado se encontrava gozando de liberdade provisória, visto que, sete meses antes, foi preso em flagrante pela mesma prática delitiva e recebeu a liberdade provisória, respondendo ao processo em liberdade e sofrendo condenação em primeira instância (cf. certidão de fls. 77, proc. 0000074-71.2021 da 3ª Vara Criminal local). Ainda que eventualmente não sofra condenação criminal definitiva naquele feito, o fato de praticar crime em pleno gozo de liberdade provisória indica tratar-se de pessoa que não se intimida com a ação do Estado, que não valoriza os benefícios que a Justiça lhe concede e que, portanto, requer tratamento mais firme para que a pena cumpra as funções de prevenção e reprovação dos crimes. Destarte, necessária a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a concessão de "sursis", bem assim o direito de recorrer em liberdade, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível, inclusive a eleição do regime fechado (no caso dos autos, entendo ser desnecessário o regime mais gravoso, sendo suficiente o semiaberto), sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas se a natureza, a quantidade de drogas e as circunstâncias concretas do crime indicarem que se trata de agente que atua com maior intensidade.

Confira-se julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (149 PEDRAS DE CRACK E UMA PORÇÃO DE MACONHA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve

ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constituem elementos idôneos para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3º, do CP. In casu, não olvidando que a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a motivação concreta para estabelecer o regime fechado é extraída dos autos, qual seja, a quantidade e natureza das drogas apreendidas (149 pedras de crack e uma porção de maconha), que evidenciam a maior ousadia e periculosidade do paciente, correta a aplicação do regime mais gravoso, o fechado na hipótese, exatamente em conformidade com o disposto no art. 33, § 3º, do CP e 42 da Lei n. 11.343/06". (STJ HC 374807/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik 5ª Turma j. 22/11/2016 , publicado DJe 30/11/2016).

Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há apenas dois meses e vinte e dois dias, não tendo, ainda, preenchido o requisito objeto para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia CONDENO o réu LUAN HENRIQUE MONTEIRO MACHADO a cumprir dois anos e seis meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e a pagar duzentos e cinquenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida em poder do acusado (R\$ 85,00), cuja origem lícita não foi comprovada, é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Conforme exposto acima, o acusado respondia a outro processo pela prática de crime idêntico ocorrido há menos de oito meses dos fatos em questão, e, inclusive, gozava do benefício de liberdade provisória naquele feito quando praticou o crime em questão. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas com o réu era expressiva, tudo, pois, a indicar maior periculosidade em sua conduta e real possibilidade de reiteração criminosa. Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual é necessária para garantia da ordem pública e fica, assim, mantida. Recomende-se o réu na prisão em que ele se encontra recolhido, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo RÉU e DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MINISTÉRIO PÚBLICO foi dito que se manifestaria no prazo legal.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Saem as partes cientes da sentença proferida.

Recebo o recurso interposto. Desde já sai a defesa intimada do prazo para apresentação das razões de apelação, independentemente de nova intimação, uma vez que trata-se de processo digital e o recurso foi recebido neste momento Regularize-se o sistema informatizado. Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso. Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.